

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7039/2542

บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์อินเตอร์เครดิต
แอนด์ ทรัสต์ จำกัด

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
ธนาคาร นครหลวงไทย จำกัด (มหาชน

นาย ธเนศ ดินกาหมื่น กับพวก

โจทก์

ผู้ร้อง

ผู้คัดค้าน

จำเลย

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 115

การโอนทรัพย์สินหรือการกระทำใด ๆ ที่จะต้องถูกเพิกถอนตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 115 ต้องเป็นการโอนหรือการกระทำให้แก่เจ้าหนี้คนหนึ่งคนใดซึ่งเป็นเจ้าหนี้อยู่แล้วก่อนการโอนหรือการกระทำและทำให้เจ้าหนี้อื่น ๆ เสียเปรียบ ปรากฏว่าการทำสัญญากู้ยืมเงิน สัญญาจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง และการจดทะเบียนจำนองตลอดจนการจดทะเบียนซื้อขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง อันเป็นทรัพย์จำนองระหว่างผู้ขายและจำเลยที่ 2 ได้กระทำในวันเดียวกันและต่อเนื่องกัน และยังปรากฏว่าธนาคารผู้คัดค้านจ่ายเงินกู้ยืมให้แก่จำเลยที่ 2 หลังจากจดทะเบียนจำนองแล้ว จึงถือไม่ได้ว่าผู้คัดค้านเป็นเจ้าหนี้ของจำเลยที่ 2 อยู่แล้วก่อนจดทะเบียนจำนองที่ดินพิพาทและสิ่งปลูกสร้าง

จำเลยที่ 2 ทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพิพาทราคา 2,250,000 บาท และจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด ว. ก่อสร้างอาคารในที่ดินพิพาทอีกเป็นเงิน 1,700,000 บาทจำเลยที่ 2 กู้ยืมเงินจากผู้คัดค้านเพื่อนำมาชำระค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ยังค้างชำระอยู่

เพียง 2,000,000 บาท โดยทำสัญญาจำนองที่ดินพิพาทและสิ่งปลูกสร้างเป็นประกัน
หนี้ที่กู้ยืมมา เห็นได้ว่า ราคาที่ดินพิพาทและสิ่งปลูกสร้างมีจำนวนสูงกว่าหนี้จำนอง
มาก การที่จำเลยที่ 2 กู้ยืมเงินจากผู้คัดค้านมาชำระค่าที่ดินพิพาทและสิ่งปลูกสร้าง
ทำให้จำเลยที่ 2 มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นย่อมเป็นผลดีแก่เจ้าหนี้อื่นของจำเลยที่ 2 จึงไม่มี
กรณีที่ผู้คัดค้านจะได้เปรียบแก่เจ้าหนี้อื่น ผู้ร้องไม่อาจร้องขอให้เพิกถอนการจด
ทะเบียนจำนองระหว่างจำเลยที่ 2 กับผู้คัดค้านตามพระราชบัญญัติล้มละลายฯ
มาตรา 115 ได้

คดีสืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2535 โจทก์ฟ้องจำเลยทั้งสองขอให้ล้ม
ละลาย ศาลชั้นต้นมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของจำเลยทั้งสองเด็ดขาดเมื่อวันที่ 19
ธันวาคม 2537 และพิพากษาให้ล้มละลายเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2538 ขณะนี้ยังไม่
พ้นภาวะล้มละลาย

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า จำเลยที่ 2 เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่
48586 ตำบลบางซื่อ อำเภอดุสิต (บางซื่อ) กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ 26 ตารางวา
พร้อมสิ่งปลูกสร้าง ต่อมาวันที่ 30 เมษายน 2536 จำเลยที่ 2 ได้นำที่ดินพร้อมสิ่ง
ปลูกสร้างดังกล่าวจดทะเบียนจำนองเป็นประกันหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินไว้แก่ผู้
คัดค้าน การที่จำเลยที่ 2 จดทะเบียนจำนองภายหลังจากถูกโจทก์ฟ้องล้มละลายโดย
รู้ถึงภาวะการมีหนี้สินล้นพ้นตัวของตนเองเป็นอย่างดีแล้ว ถือได้ว่าจำเลยที่ 2 กระทำ
โดยมุ่งหมายให้ผู้คัดค้านได้เปรียบเจ้าหนี้รายอื่น ขอให้มีความสั่งเพิกถอนการจำนอง
ที่ดินโฉนดเลขที่ 48586 ตำบลบางซื่อ อำเภอดุสิต (บางซื่อ) กรุงเทพมหานคร พร้อม
สิ่งปลูกสร้างระหว่างจำเลยที่ 2 กับผู้คัดค้านตามพระราชบัญญัติล้มละลายพ.ศ. 2483

มาตรา 115 โดยให้ผู้คัดค้านไปดำเนินการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนหากผู้คัดค้านไม่ดำเนินการให้ถือเอาคำสั่งหรือคำพิพากษาของศาลเป็นการแสดงเจตนาแทนและถ้าไม่สามารถกลับคืนสู่สภาพเดิมให้ผู้คัดค้านใช้ราคาเป็นเงิน 2,000,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ศาลมีคำสั่งให้เพิกถอนการจำนอง เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่ผู้ร้อง

ผู้คัดค้านยื่นคำคัดค้าน ขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วมีคำสั่งให้เพิกถอนการจำนองที่ดินโฉนดเลขที่ 48586 ตำบลบางซื่อ อำเภอดุสิต (บางซื่อ) กรุงเทพมหานคร ระหว่างจำเลยที่ 2 ผู้จำนองกับผู้คัดค้านซึ่งเป็นผู้รับจำนองตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 ให้กลับคืนสู่ฐานะเดิมโดยให้ผู้คัดค้านไปดำเนินการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียน หากไม่ไปให้ถือเอาคำสั่งของศาลเป็นการแสดงเจตนา หากไม่สามารถกลับคืนสู่สภาพเดิมได้ ให้ผู้คัดค้านชดเชยราคาที่ดินเป็นเงินจำนวน 2,000,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ศาลมีคำสั่งให้เพิกถอนการโอนที่ดิน จนกว่าจะชำระเสร็จ

ผู้คัดค้านอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกคำร้องของผู้ร้อง

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติได้ว่า โจทก์ฟ้องจำเลยทั้งสองเป็นบุคคลล้มละลายเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2535 ต่อมาวันที่ 30 เมษายน 2536 จำเลยที่ 2 ทำสัญญากู้ยืมเงินผู้คัดค้าน 2,000,000 บาท เพื่อนำไปชำระค่าที่ดินโฉนดเลขที่ 48586 ตำบลบางซื่อ อำเภอดุสิต (บางซื่อ) กรุงเทพมหานครซึ่งจำเลยที่ 2 ทำ

สัญญาจะซื้อจะขายไว้ตามเอกสารหมายเลข 7 และคำสั่งปลูกสร้างบนที่ดินดังกล่าว โดยจำเลยที่ 2 ได้นำที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างจดทะเบียนจำนองเป็นประกันหนี้ในวันเดียวกันกับที่ทำสัญญากู้ยืมเงิน ผู้คัดค้านมอบเงินกู้ยืมให้แก่จำเลยที่ 2 หลังจากจดทะเบียนจำนองเรียบร้อยแล้ว และจำเลยที่ 2 นำเงินกู้ยืมที่ได้รับมาทั้งหมดชำระค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ได้รับโอนมา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของจำเลยทั้งสอง เด็ดขาดวันที่ 19 ธันวาคม 2537 และพิพากษาให้ล้มละลายวันที่ 11 สิงหาคม 2538 มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของผู้ร้องว่าผู้ร้องจะขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างระหว่างจำเลยที่ 2 กับผู้คัดค้าน ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 115 ได้หรือไม่ ศาลฎีกาโดยมติที่ประชุมใหญ่ เห็นว่า การโอนทรัพย์สินหรือการกระทำใด ๆ ที่จะต้องถูกเพิกถอนตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 115 ต้องเป็นการโอนหรือการกระทำในระยะเวลาสามเดือนก่อนมีการขอให้ล้มละลายและภายหลังนั้นให้แก่เจ้าหนี้คนหนึ่งคนใด ซึ่งเป็นเจ้าหนี้อยู่แล้วก่อนการโอนหรือการกระทำ และการโอนหรือการกระทำนั้นทำให้เจ้าหนี้อื่น ๆ ของลูกหนี้เสียเปรียบสำหรับคดีนี้ปรากฏว่าการทำสัญญากู้ยืมเงินสัญญาจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและการจดทะเบียนจำนองตามเอกสารหมายเลข 1 ถึง 3 ตลอดจนการจดทะเบียนซื้อขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างอันเป็นทรัพย์จำนองระหว่างผู้ขายและจำเลยที่ 2 ได้กระทำในวันเดียวกันและต่อเนื่องกัน คือในวันที่ 30 เมษายน 2536 และยังปรากฏว่าผู้คัดค้านจ่ายเงินกู้ยืมให้แก่จำเลยที่ 2 หลังจากจดทะเบียนจำนองแล้วกรณีนี้จึงถือไม่ได้ว่าผู้คัดค้านเป็นเจ้าหนี้ของจำเลยที่ 2 อยู่แล้วก่อนจดทะเบียนจำนองที่ดินพิพาทและสิ่งปลูกสร้าง นอกจากนั้นยังได้ความว่าจำเลยที่ 2 ทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพิพาทราคา 2,250,000 บาท และจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด ว. ทวีชัยสหกิจการสร้างอาคารในที่ดินพิพาทอีกเป็นเงิน 1,700,000 บาท รวมราคาที่ดินพิพาทและสิ่งปลูกสร้างเป็นเงิน 3,950,000 บาท จำเลยที่ 2 กู้ยืมเงินจากผู้คัดค้านเพื่อนำมาชำระค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ยังค้างชำระอยู่เพียง

2,000,000บาท และทำสัญญาจ้างอยู่ที่ดินพิพาทและสิ่งปลูกสร้างเป็นประกันหนี้ที่กู้ยืมมา เห็นได้ว่าราคาที่ดินพิพาทและสิ่งปลูกสร้างมีจำนวนสูงกว่าหนี้จ้างมาก การที่จำเลยที่ 2 กู้ยืมเงินจากผู้คัดค้านมาชำระค่าที่ดินพิพาทและสิ่งปลูกสร้างทำให้จำเลยที่ 2 มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้น ย่อมเป็นผลดีแก่เจ้าหนี้อื่นของจำเลยที่ 2 จึงไม่มีกรณีที่ผู้คัดค้านจะได้เปรียบแก่เจ้าหนี้อื่น ผู้ร้องไม่อาจจะร้องขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนจ้างระหว่างจำเลยที่ 2 กับผู้คัดค้านตามพระราชบัญญัติล้มละลายพ.ศ. 2483 มาตรา 115 ได้ ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษามานั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วยฎีกาของผู้ร้องฟังไม่ขึ้น"

พืพำกษำยััน

(ไพโรจน์ คำอ่อน-ทองเลื่อน พูลพิพัฒน์-ชวลิต ยอดเนร)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

๒
ต้น

หมายเหตุ

ในการที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะขอให้เพิกถอนการโอนทรัพย์สิน หรือการกระทำใด ๆ ซึ่งลูกหนี้ได้กระทำ หรือยินยอมให้กระทำ โดยมุ่งหมายให้เจ้าหนี้คนหนึ่งคนใดได้เปรียบเจ้าหนี้อื่นตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 115 นั้น ผู้รับโอนหรือผู้รับประโยชน์จะต้องมีฐานะเป็นเจ้าหนี้ของลูกหนี้อยู่ก่อนที่ลูกหนี้จะกระทำการอันเป็นเหตุที่จะร้องขอให้เพิกถอนการโอนนั้น กล่าวคือเจ้าหนี้กับลูกหนี้มีนิติ

สัมพันธ์กันมาก่อนแล้วอันเป็นการก่อสิทธิให้แก่เจ้าหนี้ที่จะเรียกร้องให้ลูกหนี้ชำระหนี้ได้ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1359/2534) การที่จะพิจารณาว่าผู้รับโอน หรือผู้รับประโยชน์มีฐานะเป็นเจ้าหนี้อยู่แล้วหรือไม่นั้นเป็นปัญหาสำคัญเพราะว่าหากผู้รับโอน หรือผู้รับประโยชน์ไม่มีฐานะเป็นเจ้าหนี้แล้วเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ก็จะขอให้เพิกถอนการโอนทรัพย์สินหรือการกระทำใด ๆ ตามมาตรานี้ไม่ได้ การที่จะพิจารณาว่าผู้รับโอนหรือผู้รับประโยชน์มีฐานะเป็นเจ้าหนี้หรือไม่นั้นหากว่าเป็นกรณีทั่ว ๆ ไป เช่น ลูกหนี้ผ่อนชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 978/2485) ชำระหนี้ให้เจ้าหนี้เงินกู้ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3181/2524) โอนที่ดินให้เจ้าหนี้ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4946/2539) โอนที่ดินตีใช้หนี้ให้เจ้าหนี้จำนอง (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2829/2524, 5225/2534) สามารถมองเห็นได้ชัดว่าผู้รับโอนหรือผู้รับประโยชน์มีฐานะเป็นเจ้าหนี้อยู่แล้ว แต่บางครั้งเป็นปัญหาซับซ้อนจะต้องนำทั้งข้อเท็จจริงและหลักกฎหมายตลอดจนแนวบรรทัดฐานของศาลฎีกามาประกอบการพิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วนว่าผู้รับโอนหรือผู้รับประโยชน์มีฐานะเป็นเจ้าหนี้อยู่แล้วหรือไม่ เช่น สัญญาซื้อขาย ในกรณีที่ลูกหนี้ขายทรัพย์สินให้แก่ผู้รับโอน จะถือว่าผู้รับโอนมีฐานะเป็นเจ้าหนี้ก่อนแล้วหรือไม่ เดิม คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 398/2530, 2907/2531, 3227/2532 วินิจฉัยว่าการซื้อขายที่ดินและตึกแถวเป็นสัญญาต่างตอบแทนอย่างหนึ่ง ทันทีกู้ยืมทำสัญญาตกลงซื้อขายและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ทั้งสองฝ่ายต่างมีหนี้ที่จะต้องปฏิบัติชำระต่อกัน ดังนั้น เมื่อผู้คัดค้านตกลงซื้อที่ดินและตึกแถวพิพาทกับจำเลย ผู้คัดค้านในฐานะผู้ซื้อจึงมีหนี้ที่จะต้องชำระราคาแก่จำเลยผู้ขาย และจำเลยก็มีหนี้ที่จะต้องชำระ คือ โอนทรัพย์สินที่ตกลงขายนั้นแก่ผู้คัดค้านผู้คัดค้านจึงอยู่ในฐานะเป็นเจ้าหนี้ที่จะได้เปรียบเจ้าหนี้อื่นตามความหมายของพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 115 แล้ว ต่อมา คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 854/2534(ประชุมใหญ่) วินิจฉัยกลับแนวคำพิพากษาศาลฎีกาข้างต้นว่า การร้องขอเพิกถอนการโอนตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483

มาตรา 115 นั้น ต้องเป็นการโอนให้แก่เจ้าหนี้ซึ่งมีฐานะเป็นเจ้าหนี้อยู่ก่อนมีการโอน และการโอนนั้นทำให้เจ้าหนี้อื่น ๆ ของจำเลยเสียเปรียบเพราะการที่จำเลยนำทรัพย์สินเท่าที่มีไปชำระเจ้าหนี้คนใดโดยเฉพาะเป็นการให้เปรียบเจ้าหนี้คนนั้น และทำให้เจ้าหนี้คนอื่นเสียเปรียบกฎหมายมุ่งคุ้มครองบรรดาเจ้าหนี้ด้วยกัน ซึ่งเป็นหนี้อยู่ก่อนมิให้ได้เปรียบแก่กัน จำเลยโอนขายฝากที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างให้แก่ ช. หลังโจทก์ฟ้องคดีล้มละลายไม่ถึงหนึ่งเดือน แม้จะเป็นการโอนตามสัญญาต่างตอบแทนซึ่งทำให้ ช. มีฐานะเป็นเจ้าหนี้ตามสัญญาขายฝากก็ตาม แต่เมื่อ ช. ผู้รับโอนมิได้มีฐานะเป็นเจ้าหนี้ของจำเลยก่อนทำสัญญาขายฝากและ ช. ผู้รับโอนเข้าทำสัญญากับจำเลยโดยไม่ทราบความมีหนี้สินล้นพ้นตัวของจำเลยจึงเพิกถอนการโอนตามมาตรา 115 ไม่ได้ หลังจากนั้นก็มีคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1049/2536, 1608/2536 และคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 8385/2540 วินิจฉัยตาม สัญญาจะซื้อจะขาย ในกรณีที่ลูกหนี้ทำสัญญาจะซื้อจะขายทรัพย์สินกับผู้รับโอนไว้ก่อนแล้ว แต่ได้มาโอนทรัพย์สินให้ในภายหลัง คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1359/2534 การโอนที่จะต้องถูกเพิกถอนตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 115 นั้น ต้องเป็นการโอนภายในระยะเวลาสามเดือนก่อนมีการขอให้ล้มละลายและภายหลังนั้น ให้แก่เจ้าหนี้คนใดคนหนึ่งซึ่งเป็นเจ้าหนี้อยู่ก่อนแล้วก่อนโอน และการโอนนั้นทำให้เจ้าหนี้คนอื่น ๆ เสียเปรียบ ที่ว่าต้องเป็นเจ้าหนี้อยู่แล้วก่อนโอนนั้น หมายความว่าเจ้าหนี้กับลูกหนี้มีนิติสัมพันธ์กันมาก่อนแล้ว อันเป็นการก่อสิทธิแก่เจ้าหนี้ที่จะเรียกร้องให้ลูกหนี้ชำระหนี้ได้ การที่จำเลยทำสัญญาจะซื้อจะขายบ้านและที่ดินพิพาทให้แก่ผู้คัดค้านไว้ก่อนแล้วผู้คัดค้านจึงมีฐานะเป็นเจ้าหนี้ของจำเลยในส่วนที่จะเรียกให้โอนบ้านและที่ดินพิพาทให้แก่ผู้คัดค้านตามสัญญาจะซื้อจะขายอยู่ก่อนแล้วก่อนโอน เมื่อพิจารณาแนวคำพิพากษาศาลฎีกาข้างต้น ผู้บันทึกเห็นว่า ในเวลาปัจจุบันน่าจะถือเป็นยุติว่ากรณีที่ลูกหนี้โอนทรัพย์สินตามสัญญาซื้อขายนั้น ผู้รับโอนไม่มีฐานะเป็นเจ้าหนี้ในขณะที่รับโอนทรัพย์สิน แต่หากว่าลูกหนี้เพียงแต่ทำสัญญาจะซื้อจะขายไว้ และลูกหนี้ได้รับชำระราคาแล้ว ต่อมาลูกหนี้

ได้โอนที่ดินให้แก่ผู้รับโอนตามสัญญาจะซื้อจะขายนั้นผู้รับโอนก็จะมีฐานะเป็นเจ้าหนี้ สัญญาอืม จำนอง ในกรณีที่ลูกหนี้กู้ยืมเงินจากเจ้าหนี้แล้วนำทรัพย์สินจำนองประกัน หัน ในการที่จะเพิกถอนสัญญาจำนอง มีปัญหาว่าขณะที่ลูกหนี้จำนองทรัพย์สินนั้น ผู้รับจำนองมีฐานะเป็นเจ้าหนี้หรือไม่ มีคำพิพากษาศาลฎีกาวินิจฉัยไว้ในกรณีต่าง ๆ ดังนี้ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3611/2526, 1567/2534 จำนองเป็นสัญญาที่เอา ทรัพย์สินตราไว้เป็นประกันการชำระหนี้ จึงมีหนี้ที่จะชำระแก่กันอันเป็นหนี้ประธาน ส่วนหนึ่งคือ หนี้เงินกู้ยืมที่ลูกหนี้รับไปก่อนทำสัญญาและจดทะเบียนจำนอง ส่วน จำนองที่ลูกหนี้ได้ทำสัญญาและจดทะเบียนให้เจ้าหนี้นั้น เป็นแต่เพียงอุปกรณ์แห่งหนี้ เงินกู้ยืมอันเป็นหนี้ประธาน ซึ่งเป็นหนี้คนละส่วนแยกออกจากกันได้ ดังนั้นเมื่อเจ้า หนี้ได้มอบเงินที่กู้ยืมให้ลูกหนี้รับไป การกู้ยืมได้เกิดขึ้น เจ้าหนี้จึงตกอยู่ในฐานะเป็น เจ้าหนี้ในทันทีนั่นเอง หลังจากนั้นแม้จะเป็นวันเดียวกันลูกหนี้ได้ทำสัญญาและจด ทะเบียนจำนองที่ดินเป็นประกันหนี้เงินกู้ดังกล่าวให้แก่เจ้าหนี้ กรณีถือได้ว่าเจ้าหนี้ เป็นเจ้าหนี้ของลูกหนี้อยู่ก่อนแล้วในขณะที่มีการทำสัญญาและจดทะเบียนจำนอง ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 115 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6967/2537 ขณะที่ลูกหนี้ทำสัญญาค้ำประกันสัญญาขายลดตัวเงินของ ว. ต่อผู้ คัดค้าน ว. ยังมีได้นำตัวเงินมาขายลดให้แก่ผู้คัดค้านนี้ตามสัญญาขายลดตัวเงินจึง ยังไม่เกิดขึ้น อันเป็นผลให้ผู้คัดค้านมีความผูกพันในฐานะเป็นเจ้าหนี้ของลูกหนี้นับ แต่วันทำสัญญาค้ำประกัน การที่ลูกหนี้จดทะเบียนจำนองที่ดินพิพาทไว้แก่ผู้คัดค้าน ในวันเดียวกัน แล้ว ว. จึงนำตัวสัญญาใช้เงินมาขายลดให้แก่ผู้คัดค้านและรับเงินจาก ผู้คัดค้านไป จึงถือไม่ได้ว่าผู้คัดค้านเป็นเจ้าหนี้ของลูกหนี้อยู่แล้วก่อนการจดทะเบียน จำนองที่ดินพิพาท เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ไม่อาจร้องขอให้เพิกถอนการจำนอง ที่ดินพิพาทตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 115 ได้ ตามแนวคำ พิพากษาศาลฎีกาข้างต้น ทำให้มองเห็นว่า การที่จะพิจารณาว่าผู้รับโอนหรือผู้รับ ประโยชน์มีฐานะเป็นเจ้าหนี้หรือไม่นั้น ให้ดูว่า ในขณะลูกหนี้จำนองทรัพย์สินเป็น

ประกันนั้น เจ้าหนี้มีสิทธิเรียกร้องต่อลูกหนี้แล้วหรือไม่ ต่อมาในปี พ.ศ. 2540 มีคำพิพากษาศาลฎีกาอยู่ 2 เรื่อง คือ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4363/2540 ผู้คัดค้านยอมตกลงให้จำเลยที่ 2 กู้เงินโดยจำนองที่ดินพิพาทไว้เป็นประกันหนี้เงินกู้ของตนเอง และหนี้เงินกู้ของ อ. ที่จำเลยที่ 2 ต้องรับผิดชอบอย่างลูกหนี้ร่วมตามสัญญาจำนอง ซึ่งการจำนองเป็นสัญญาที่เอาทรัพย์สินตราไว้เป็นประกันการชำระหนี้เงินกู้ อันเป็นหนี้อุปกรณ์ของหนี้เงินกู้ซึ่งเป็นหนี้ประธานจึงเป็นหนี้คนละส่วนแยกจากกันได้ กรณีเป็นการจำนองเพื่อหนี้ในอนาคตตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 707 สัญญากู้เงินและสัญญาจำนองที่จำเลยที่ 2 ต้องรับผิดชอบร่วมกับ อ. ได้เกิดขึ้นแล้วก่อนการจำนอง แม้ผู้คัดค้านยังไม่จ่ายเงินให้จำเลยที่ 2 หรือ อ. ตามสัญญากู้เงิน จนกว่าจะได้จดทะเบียนจำนองก็ไม่ใช่สาระสำคัญ เพราะการจ่ายเงินให้แก่จำเลยที่ 2 หรืออ. ก็เป็นผลมาจากสัญญากู้เงินที่มีต่อกัน โดยมีการจำนองที่ดินพิพาทเป็นประกันเท่านั้นผู้คัดค้านจึงมีฐานะเป็นเจ้าหนี้ของจำเลยที่ 2 ตามสัญญากู้เงินและสัญญาจำนองอยู่ก่อนแล้วในขณะที่มีการจดทะเบียนจำนอง เมื่อจำเลยที่ 2 นำที่ดินพิพาทมาจดทะเบียนจำนองไว้แก่ผู้คัดค้านภายหลังจากโจทก์ฟ้องจำเลยที่ 2 ให้ล้มละลายโดยมุ่งหมายให้ผู้คัดค้านได้เปรียบเจ้าหนี้อื่น เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จึงร้องขอให้เพิกถอนการจำนองที่ดินพิพาทตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 115 ได้ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 7441/2540 การจำนองเป็นสัญญาที่เอาทรัพย์สินตราไว้เป็นประกันการชำระหนี้ จึงมีหน้าที่ที่ต้องชำระแก่กันอันเป็นหนี้ประธานส่วนหนึ่งคือ หนี้เงินกู้ที่ผู้คัดค้านจ่ายเงินให้จำเลยรับไป ส่วนจำนองที่จำเลยทำสัญญาและจดทะเบียนให้แก่ผู้คัดค้านนั้นเป็นเพียงอุปกรณ์แห่งหนี้อันเป็นประธาน ซึ่งเป็นหนี้กันคนละส่วนซึ่งแยกออกจากกันได้ การกู้เงินคดีนี้จำเลยได้รับเงินจากผู้คัดค้านไปแล้วในวันทำสัญญา และเพื่อเป็นหลักประกันที่จำเลยจะปฏิบัติตามสัญญาจำเลยได้นำที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่พิพาทมาจำนองเป็นประกันหนี้ดังกล่าวไว้แก่ผู้คัดค้าน เช่นนี้ การที่จำเลยกู้เงินผู้คัดค้านและได้รับเงินจากผู้คัดค้านไปแล้วในทันทีทันใดนั้น การกู้เงิน

ระหว่างผู้คัดค้านและจำเลยได้เกิดขึ้นแล้ว หลังจากนั้นแม้จะเป็นวันเดียวกันจำเลย
มาทำสัญญาจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างกับผู้คัดค้านอีก กรณีถือได้ว่าผู้คัดค้านเป็น
เจ้าหนี้ของจำเลยอยู่ก่อนแล้วในขณะที่มีการทำสัญญาและจดทะเบียนจำนองรายนี้
ตามพระราชบัญญัติล้มละลายพ.ศ. 2483 มาตรา 115 เมื่อพิจารณาคำพิพากษาศาล
ฎีกาที่ 4363/2540 และคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 7441/2540 แล้ว เห็นว่า คำพิพากษา
ศาลฎีกาทั้งสองฉบับน่าจะวินิจฉัยหลักกฎหมายในเรื่องนี้ไปคนละแนวกัน หลังสุด
ศาลฎีกาก็มีคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 7039/2542(ประชุมใหญ่) ที่บันทึกวินิจฉัยว่า การ
ทำสัญญากู้ยืมเงิน สัญญาจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและการจดทะเบียนจำนอง
ตลอดจนการจดทะเบียนซื้อขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างอันเป็นทรัพย์สินจำนองระหว่าง
ผู้ขายและจำเลยที่ 2 ได้กระทำในวันเดียวกัน และต่อเนื่องกัน และยังปรากฏว่าผู้
คัดค้านจ่ายเงินกู้ยืมให้แก่จำเลยที่ 2 หลังจากจดทะเบียนจำนองแล้ว กรณีจึงถือไม่
ได้ว่า ผู้คัดค้านเป็นเจ้าหนี้ของจำเลยที่ 2 อยู่แล้วก่อนจดทะเบียนจำนองที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้าง ผู้บันทึกจึงเห็นว่า คำพิพากษาศาลฎีกาโดยมติที่ประชุมใหญ่นี้ วินิจฉัยตาม
แนวคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3611/2526, 1567/2534, 6967/2537 และ
7441/2540 โดยไม่ได้วินิจฉัยตามแนวคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4363/2540 แต่อย่างใด
นั่นก็คือการที่จะพิจารณาว่าผู้รับโอนหรือผู้รับประโยชน์นั้นมีฐานะเป็นเจ้าหนี้อยู่
ก่อนแล้วหรือไม่จะต้องพิจารณาจากข้อเท็จจริงในคดีนั้นเป็นเรื่อง ๆ ไป มีปัญหา
คิดในทางปฏิบัติในการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินปัจจุบันนี้ ซึ่งผู้กู้จะต้องทำสัญญา
กู้ยืมและจดทะเบียนจำนองเสร็จแล้วจึงจะได้รับเงินที่กู้ยืม หรือเมื่อจดทะเบียนจำนอง
เสร็จแล้ว เจ้าหนี้ที่ของสถาบันการเงินจึงส่งมอบเงินที่กู้ยืมให้ อย่างไรก็ตามขณะที่
จดทะเบียนจำนองนั้นผู้รับจำนองมีฐานะเป็นเจ้าหนี้อยู่แล้วหรือไม่ และกรณีจะแตกต่างกันหรือไม่ ถ้าหากว่าขณะที่ไปจดทะเบียนจำนองนั้นแต่ก่อนที่เจ้าพนักงานจะ
จดทะเบียนจำนอง เจ้าหนี้ที่ของสถาบันการเงินได้ส่งมอบเงินให้แก่ลูกหนี้ไปก่อน เอื้อน
ขุนแก้ว